



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
II. Actuación administrativa y gestión financiera

**Tema 7. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía
de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Gobierno con
fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento:
concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho
administrativo**

AUTOR: Sergio MIGUEL MARTIN.
REVISOR: Jose Carlos MARTINEZ DURILLO.

Creación: noviembre 2020
Actualización: 10/2020

ÍNDICE

1	FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.....	3
1.1	INTRODUCCIÓN	3
1.2	FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SUS CLASES.	3
1.2.1	CLASES.....	3
1.3	CONCLUSIONES.....	5
2	JERARQUÍA DE FUENTES	6
2.1	INTRODUCCIÓN.....	6
2.2	PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA.....	6
2.3	CONCLUSIONES.....	7
3	LA LEY.....	8
3.1	INTRODUCCIÓN.....	8
3.2	CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y CLASES.....	8
3.3	CARACTERÍSTICAS DE LA LEY	8
3.4	REQUISITOS DE LA LEY	9
3.5	CLASES DE LEYES:	9
3.6	LEYES ORGÁNICAS.....	10
3.7	LEYES ORDINARIAS.....	11
4	DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY.....	12
4.1	INTRODUCCIÓN.....	12
4.2	NORMAS GUBERNAMENTALES CON FUERZA DE LEY.	12
4.2.1	EL REAL DECRETO LEGISLATIVO	12
4.2.2	EL REAL DECRETO-LEY	14
4.3	CONCLUSIONES.....	14
5	EL REGLAMENTO CONCEPTO, CLASES Y LIMITES.	15
5.1	INTRODUCCIÓN	15
5.2	CARACTERÍSTICAS.....	15
5.3	DIFERENCIACIÓN.	15
5.3.1	DIFERENCIA CON EL ACTO ADMINISTRATIVO.	16
5.3.2	DIFERENCIA CON LOS DECRETOS LEYES Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS.....	16
5.4	CLASES DE REGLAMENTOS.	16
5.4.1	POR LA RELACIÓN DEL REGLAMENTO CON LA LEY:	16
5.4.2	POR RAZÓN DE LOS EFECTOS:	16
5.4.3	POR SU ORIGEN:	17
5.5	LA POTESTAD REGLAMENTARIA.....	17
5.5.1	TITULARIDAD DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA.	17
5.5.2	LÍMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA.	18
5.5.2.1	LÍMITES FORMALES:	18
5.5.2.2	LÍMITES MATERIALES	19
5.5.3	CONSIDERACIONES ADICIONALES	20

5.6	PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS.....	20
5.7	LÍMITES DE LOS REGLAMENTOS.	20
5.8	CONTROL DE LOS REGLAMENTOS.	21
5.8.1	LA NULIDAD DE PLENO DERECHO	21
5.8.2	LA INAPLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS.	21
5.8.3	DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD DE LOS REGLAMENTOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.	21
5.9	CONCLUSIONES.	21
6	OTRAS FUENTES DE DERECHO ADMINISTRATIVO.....	23
6.1	INTRODUCCIÓN.	23
6.2	LA COSTUMBRE	23
6.2.1	TIPOS DE COSTUMBRE:	23
6.2.2	LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.	24
6.2.3	LA JURISPRUDENCIA.....	24
6.2.4	CONCLUSIONES	25
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	26
8	GLOSARIO	29
9	TEST	30
9.1	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	32
10	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	33

1 Fuentes del derecho administrativo

1.1 Introducción

Cuando hablamos de fuentes del derecho, se alude en especial al término fuentes, con el significado del origen o procedencia del derecho, de las normas jurídicas. **Sin el conocimiento de las fuentes, no tendríamos derecho.** Es la historia del derecho la que ayuda a comprender como se han aplicado las fuentes

1.2 Fuentes del derecho administrativo y sus clases.

La **teoría general de fuentes** se recoge en el Artículo 1 del Código Civil (común para todas las ramas del derecho, aunque luego cada una tiene su especialidad). Este artículo **no incluye los reglamentos los cuales son una fuente del derecho administrativo.**

*1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son **la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.***

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

De forma análoga al Derecho Civil, el concepto técnico jurídico de las fuentes del derecho tiene dos acepciones: **material y formal.**

Fuente en **sentido formal es la forma externa que adopta o el modo en que se exteriorizan las normas jurídicas**, como menciona el artículo 1 del Código Civil son **la Ley, la Costumbre, y los Principios Generales del Derecho.**

Fuente en **sentido material alude la institución o instituciones que tienen la potestad normativa creadora atribuida para producir normas jurídicas.** Pudiendo en este caso ser creadas por el Estado, las Comunidades Autónomas (leyes y reglamentos en ambos casos) o el pueblo (la costumbre).

1.2.1 Clases

Según su proclamación pueden ser **fuentes escritas** porque la escritura es necesaria para que cause efecto como las leyes y reglamentos o bien **no escritas** como la costumbre

Según el origen, podemos clasificar por tener **origen en los poderes estatales** como **las leyes y reglamentos**, o bien tienen **su origen en el pueblo** como la **costumbre.**

Por **fuentes primaria** (la ley) se entiende aquella que se aplica en primer lugar, el resto son **secundarias**.

Podemos distinguir también entre **fuentes directas** y **fuentes indirectas**, siendo las primeras las que contienen normas jurídicas y las segundas no contienen normas

Dentro de las fuentes directas tenemos:

- **Fuentes escritas:** la Constitución, la ley, los Tratados internacionales, los reglamentos estatales y los reglamentos dictados por otras entidades públicas. El Derecho Administrativo español está dominado por el principio de la ley escrita.
- **Fuentes no escritas:** la costumbre y los Principios Generales del Derecho.

Siendo el reglamento la fuente directa más importante para el derecho administrativo. La **costumbre tiene una reducida importancia** y lo son cada vez más los **Principios Generales del Derecho, en especial como límite al ejercicio de la actividad discrecional**.

Las fuentes indirectas, por sí solas, no contienen una norma jurídica, si bien ayudan a comprenderlo exteriorizarlo. Son ejemplos de estas la Jurisprudencia, los Tratados Internacionales, la Doctrina científica o doctrina de los autores ...”

Destacar también el papel del **Tribunal Constitucional** como **legislador negativo** pues una **declaración de inconstitucionalidad de una ley equivale a su salida del reglamento jurídico**.

El término “legislador negativo” hace una referencia al modelo introducido por Hans Kelsen, donde el Tribunal Constitucional, actuar como contrapoder al poder legislativo. El poder legislativo “pone” o añade normas. La labor del Tribunal Constitucional, no es añadir, al contrario, es quitar del ordenamiento jurídico aquellos elementos que no respetan unas mínimas exigencias constitucionales.

Mencionar por último el tema del denominado “**precedente administrativo**”

La pregunta que se suscita es el grado de vinculación a que está sometida la Administración cuando, al enfrentarse con un supuesto similar al ya resuelto con una misma norma, deba de respetar la interpretación y decisión adoptada anteriormente. Dado que el precedente no se asimila a la costumbre ni constituye, en ningún caso, fuente del derecho Administrativo.

En el derecho español, no hay vinculación entre la actuación previa, salvo en determinados supuestos, pues la actuación de las administraciones bajo el principio de legalidad, implica que la administración debe aplicar la norma jurídica y llegar a idéntica solución. El precedente administrativo debe ser tenido en cuenta cuando la norma permite una doble o plural interpretación.

La generalidad de la doctrina consiste en **reconocer al precedente fuerza vinculante siempre que se dé, identidad subjetiva y objetiva sustancial entre ambos supuestos comparados**.

No obstante, **si el acto invocado como precedente es ilegal o bien cuando concurren factores de interés público, la Administración puede separarse del precedente y resolver en sentido distinto** (artículo 35.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Adicionalmente en el mismo artículo se expone que han de estar motivados aquellos actos administrativos “*que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes*”. La ausencia de motivación implica la anulabilidad del acto en especial cuando causa indefensión (art 48.2 de la misma ley).

1.3 Conclusiones

Un sistema de fuentes es producto de factores políticos, históricos, sociológicos, e ideológicos. Actualmente, en el ordenamiento español, el predominio de la ley como fuente del derecho indica la intensidad creciente del poder del Estado y de su organización y actividades frente a las normas espontáneas de creación del derecho como en otras épocas pudo ser la costumbre.

2 Jerarquía de Fuentes

2.1 Introducción.

El orden jerárquico de las fuentes tiene interés pues **determina el orden de aplicación de las normas** al caso concreto, así como el criterio para solucionar las prescripciones contradictorias contenidas en normas de rango distinto.

2.2 Principio de Jerarquía Normativa.

Las normas integrantes del derecho Administrativo están sujetas al **principio de jerarquía normativa**, que se encuentra reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución.

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

A su vez, el Código Civil lo recoge en su artículo 1.2 al disponer que:

“carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior”.

La jerarquía de las fuentes determina el orden de aplicación al caso concreto, de modo que **solo en ausencia de fuente superior se aplica la inferior**. Además, determina la invalidez de la norma inferior que contradiga lo dispuesto por la superior (artículo 1.2 del Código Civil). Esta misma consecuencia es la que ha previsto la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 47.2:

“También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”

En virtud del **principio de jerarquía normativa** las **normas de rango superior prevalecen y se imponen sobre las de rango inferior**. Las normas que ostentan el mismo rango tienen la misma fuerza normativa.

Por otra parte, este principio permite constatar la relación existente **entre la fuente de la que emana** cada norma (el órgano que la produce) y **la forma** de la misma, así como su rango y fuerza.

Corresponde a la Constitución determinar las potestades normativas y la atribución del rango en virtud de la fuente de la que proceden. **De esta forma todas las normas procedentes de la misma fuente tienen, en principio, la misma forma externa y la misma fuerza** (leyes, decretos, etc.).

En virtud de este principio (Ver Fig. 1), **la cúspide normativa es la Constitución, norma suprema que prevalece y se impone a todas las demás**. En segundo lugar, se encuentran las **leyes y las disposiciones del Gobierno con rango de Ley** (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos), y en este mismo nivel **se hallarían los Tratados Internacionales publicados en el B.O.E.** También hay que tener en cuenta **las leyes y reglamentos emanados de las Comunidades Autónomas**.

Un tercer nivel **lo constituyen los Reglamentos**, que también tienen una ordenación jerárquica. De acuerdo con el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones administrativas **se ajustarán al orden de jerarquía**

que establezcan las leyes (artículo 128.3) y ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior (artículo 128.2).



Fig 1 Jerarquía Normativa

2.3 Conclusiones.

Existen dos criterios fundamentales: **Primacía del Derecho escrito** y **la jerarquía del órgano del que emana la norma**, prima la Constitución y se subordinan las disposiciones administrativas a las del poder legislativo.

Con dos implicaciones:

- **A mayor jerarquía del órgano** que dicta la norma administrativa, ésta tiene **mayor rango formal**
- Las normas reglamentarias de las entidades de carácter público integradas en el Estado **no pueden contradecir el Derecho estatal**.

3 La Ley

3.1 Introducción.

En sentido formal, **ley es toda norma jurídica dictada por los órganos a los que el ordenamiento jurídico atribuye poder legislativo**. Con la Constitución Española de 1978 **las normas legislativas se han enriquecido: aparecen leyes orgánicas (y dentro de estas, los Estatutos de Autonomía), leyes ordinarias, leyes de las CC.AA., leyes marco, leyes de transferencias y leyes de armonización**. Además, una serie de normas con fuerza de ley, como **son los Decretos Leyes y Decretos Legislativos**.

3.2 Características, requisitos y clases.

La ley en **sentido amplio se asimila a “norma jurídica” o Derecho** (Artículos 9, 10, 11 del CC). En **un sentido más restringido** se podría entender por ley **una norma jurídica escrita (artículo 1.2 del CC)**.

Sin embargo, **en un sentido aún más estricto** una ley es la **norma de origen parlamentario, de rango subordinado a la Constitución, e irresistibles e indiscutibles en el ámbito jurídico**.

Requieren especiales requisitos y solemnidades, que se contraponen a los reglamentos o disposiciones administrativas de rango inferior. Artículo 66.2 de la Constitución establece que:

“Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.”

En el ámbito administrativo la ley es solamente la norma jurídica de carácter general y obligatorio emanada del órgano estatal titular del Poder Legislativo.

La anterior definición no es solo la parte **formal** de la ley (como norma jurídica general y obligatoria) sino además su parte **material** (emanada del Legislativo)

3.3 Características de la Ley

Algunas características propias del término ley, dentro del derecho, son:

- **Obligatoriedad.** Todas y cada una de las personas deben respetar y cumplir las leyes, incluso cuando estas estén en contra de su propia voluntad. Adicionalmente el cumplimiento de la ley se establece en el artículo 6.1 del Código Civil *“la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”*
- **Impersonalidad.** Se aplican a un número indeterminado de personas.
- **Abstracción.** Pues implican a un número de casos ni establecidos ni particularizados, aun existiendo unos supuestos determinados en las normas, se aplican a todos los casos con los mismos supuestos.
- **Permanencia.** Alude a que estas son formuladas **con carácter indefinido y permanente**. La subrogación, abrogación o derogación a partir de leyes posteriores, causa la no vigencia de la ley.
- **Generalidad.** Esto implica que son **aplicables a todos aquellos individuos** que presenten las condiciones determinadas en ellas mismas.
- **Irretroactividad.** La **irretroactividad es el principio general y la retroactividad la excepción**; dicha retroactividad puede tener lugar tanto cuando la ley la disponga (**retroactividad expresa**), como cuando del sentido de la norma se desprenda que éste fue el propósito del legislador, es decir, cuando por la vía de la interpretación pueda deducirse tal

carácter retroactivo (**retroactividad tácita**). El Tribunal Supremo tiene declarado que el apartado 3º del artículo 2º del Código Civil establece taxativamente que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario. El art 9.3 CE indica *“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”*

3.4 Requisitos de la Ley

- **Requisitos Internos:**
 - **Generalidad:** Hemos revisado ya este concepto.
 - **Imperatividad:** Contiene un mandato ya sea positivo o negativo.
 - **Coercibilidad:** El mandato debe ser susceptible de ser impuesto por medio de la coacción externa,
 - **Racionalidad:** El mandato debe ser racional o justo.
- **Requisitos Externos:**
 - Las leyes han de ser **elaboradas y aprobadas** según procedimiento legalmente establecido, además de **sancionadas, promulgadas y publicadas**.

3.5 Clases de leyes:

Existen dos grandes grupos; **leyes orgánicas y leyes ordinarias**.

Las leyes orgánicas que tienen un contenido material limitado, puesto que únicamente pueden **regular aquellas materias concretas en las que la Constitución exige este tipo de leyes**, en cambio, **las leyes ordinarias no tienen esta limitación material**.

Las siguientes materias quedan reservadas a Ley Orgánica (art 81CE):

- a) Desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
- b) Estatutos de Autonomía
- c) Régimen electoral general
- d) Demás previstas en la Constitución.

A modo de ejemplo del inciso d), las demás previstas en la Constitución, tenemos el art 135.5 CE

“5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

- a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.*
- b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.*

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.”

En cuanto al procedimiento de aprobación, las **leyes orgánicas precisan la mayoría absoluta** del Congreso de los Diputados, cuando **las leyes ordinarias** solo requieren la mayoría simple.

La Constitución se refiere a diversos tipos de leyes que, **bien en su elaboración o en su aplicación, presentan alguna especialidad**. Entre las diferentes clases de leyes, pueden distinguirse las siguientes:

- a) **Leyes de Bases**, son una delegación legislativa que las Cortes hacen al Gobierno para la formación de textos articulados en las materias y con aquellos requisitos expresamente fijados por la Constitución (art. 82 CE).
- b) **Leyes Marco**, que son aquellas en que, por atribución de las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas reciben la facultad de dictar, en materias de competencia estatal y para sí mismas, normas legislativas en el “marco de los principios, bases y directrices que fije la ley (art. 150.1 CE)
- c) **Leyes de Transferencia**, que son leyes orgánicas a través de las cuales el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas facultades que corresponden a materias de las que es titular el Estado (art. 150.2 CE).
- d) **Leyes de Armonización** establecen, por parte del Estado, aquellos principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas siempre y cuando sea de interés general (art. 150.3 CE).
- e) **Legislación Básica**, que son las leyes que contienen los principios y aspectos fundamentales de la regulación de una determinada materia sobre la que tienen competencia legislativa tanto el Estado como las Comunidades Autónomas.
- f) **Leyes de Presupuestos**. La especialidad más característica de estas leyes es que su elaboración y, por consiguiente, la iniciativa, corresponde exclusivamente al Gobierno. Teniendo un desarrollo parlamentario singular, precisándose la conformidad del Gobierno para la tramitación de las enmiendas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Estas leyes tienen una serie de limitaciones y así no pueden crear tributos (art. 134.7 CE), ni regular materias que no tengan una relación directa con los ingresos y gastos, como ha declarado el Tribunal Constitucional.

3.6 Leyes Orgánicas.

Artículo 81 de la Constitución Española:

“Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.”

Tienen una relación de superioridad sobre la ley ordinaria por dos principios:

- **Principio de Jerarquía normativa**: Se basa en la rigidez formal que el art. 81.2 CE dio a las leyes orgánicas

- **Principio de competencia por razón de materia**, pues se acotan y separan ámbitos competenciales diferentes, cuyo tratamiento se reserva a órganos y a procedimientos determinados.

En cuanto **a los estatutos de autonomía**, además del artículo 81 de la Constitución Española, el art. 147.1 establece:

“Los estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconoce y amparará como parte integrante de su Ordenamiento Jurídico”.

El Estatuto, **como ley estatal, forma parte del Ordenamiento del Estado**, y en cuanto permite la emergencia **de un ordenamiento secundario, es la norma de cabecera del mismo**.

- La relación **del Estatuto con la Constitución es de sometimiento jerárquico**.
- La relación **del Estatuto respecto de las demás leyes del Estado es de separación estricta**. No hay una relación de jerarquía normativa, sino que es el principio de competencia quien ordena las relaciones.
- El Estatuto **tiene reservada la regulación de una serie de cuestiones que enuncia el art. 147 de la Constitución**.
- Si una ley del Estado desconoce o contradice al Estatuto es nula, y es nula, no por **desconocer la superioridad jerárquica** sino porque viola las reglas constitucionales que atribuyen funciones **distintas al Estatuto de Autonomía y a las demás leyes del Estado**.

3.7 Leyes ordinarias

Las leyes ordinarias se aprueban **por la mayoría simple de los miembros de las Cámaras (art. 79 CE)**. Lo normal es que sean aprobadas por el pleno de las Cámaras, pero **estas podrán delegar** en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Quedan excluidas de **esta delegación: la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y, los presupuestos generales** del Estado (art. 75 CE).

La Constitución establece en numerosos de sus preceptos, materias reservadas a la ley, que será ordinaria, salvo que se disponga expresamente otra cosa.

El procedimiento de elaboración **puede iniciarse por las propias Cámaras** (proposición de ley) o bien por **el Consejo de Ministros** (proyecto de ley) que, en este último caso, se enviará al Congreso y se tramitará con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos de las Cámaras, de acuerdo con los arts. 87 y 88 CE, así como en el art. 22 de la ley 50/ 1997, del Gobierno la iniciativa legislativa del Gobierno. **Debe destacarse la clara preponderancia del Congreso sobre el Senado cuya función se reduce a una mera labor de revisión.**

4 Disposiciones del Ejecutivo con Fuerza de Ley.

4.1 Introducción.

El Gobierno **no solo dicta normas de rango reglamentario**, que es su ámbito normativo propio, sino que **el Gobierno también aprueba normas con rango de ley** a pesar de no ser el representante primario de la voluntad popular. **Esto es una evolución del esquema clásico** donde es función del Parlamento la emanación de leyes y del Gobierno la producción reglamentaria.

4.2 Normas gubernamentales con fuerza de ley.

Dos son los tipos de disposiciones dictadas por el Ejecutivo con fuerza de ley:

- **Los Reales Decretos Legislativos:** Dictados por el Gobierno para legislar una materia **previa delegación del Poder Legislativo**.
- **Los Reales Decretos-Ley.** Las dictadas para afrontar **situaciones de urgente necesidad**.

Como **características comunes**:

- Desde un **aspecto subjetivo ambas emanan del Gobierno**,
- Desde un **aspecto formal tienen el mismo valor que las leyes ordinarias** que emanan del poder legislativo.

Como **aspectos diferenciales**:

- En los decretos legislativos la **intervención de las Cortes** se produce **a priori legitimándolo antes de su promulgación**. En los decretos ley, la intervención de las cortes **es posterior a la promulgación**.
- El fundamento de ambas es distinto **en los primeros la autorización al Gobierno es sobre temas concretos, en los segundos es por extraordinaria y urgente necesidad, sin participación de las cortes**.

4.2.1 El Real Decreto Legislativo

La Constitución en los artículos 82 a 86 contiene un aspecto importante en relación a las Cortes, así el artículo 82 permite a las Cortes Generales que **deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias no reservadas a la ley orgánica**: son los reales decretos legislativos.

Artículo 82 de la Constitución:

1. *Las Cortes Generales podrán delegar en el **Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley** sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. (Leyes orgánicas)*
2. *La delegación legislativa **deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.***
3. *La delegación legislativa habrá de otorgarse al **Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio**. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.*

4. **Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.**
5. **La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.**
6. **Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.**

La delegación legislativa, **consiste en una transferencia de la potestad legislativa en favor de la Administración, considerando que se trata de transferencia de ejercicio, pero no de "titularidad".** El efecto primario y esencial de la delegación legislativa **es ampliar el poder normativo de la Administración por vía singular.**

Existen dos manifestaciones de esta legislación delegada: Los **Textos Articulados de leyes de bases y Textos Refundidos**

Como se observa la delegación legislativa:

- Se otorga al poder ejecutivo **de forma expresa**, para cada **caso concreto y con fijación de plazo** para su ejercicio.
- La delegación **se agota** por el uso que haga de ella el Gobierno **mediante la publicación de la norma correspondiente.**
- **No es concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.**
- **No permite la subdelegación** o a autoridades distintas del propio Gobierno.
- El destinatario de la delegación **puede ser un Gobierno Autónomo, si la asamblea delegante es Autónoma.**

Los contenidos específicos son:

- En los **Textos Articulados** contendrá **los principios y criterios** que seguirán en su ejercicio.
- En los **Textos Refundidos** **determinará el ámbito de la refundición**, especificando si se incluye la posibilidad de aclarar y armonizar los textos legales a considerar.

La labor que se confía aquí al Gobierno es técnica y no creadora: sistematizar y articular en un texto único una pluralidad de leyes que inciden sobre un mismo objeto **sin alterar la regulación material.** Ver artículo 82.5 CE.

Los **Reales Decretos Legislativos** pueden recibir tres tipos de control:

- Los que expresamente le **establezcan las leyes de la delegación**
- El control de constitucionalidad **del Tribunal Constitucional**
- Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, las **partes del Real decreto Legislativo que se excedan de los límites de la delegación pierden su rango legal y quedan degradadas al rango reglamentario** por lo que podrán ser **revisadas por la jurisdicción contencioso-administrativa.**

Por otra parte, todo Real Decreto Legislativo, para su aprobación, debe obtener **el previo dictamen del Consejo de Estado** lo cual supone, en cierta medida, otra forma de control.

4.2.2 El Real Decreto-Ley

El artículo 86 de la Constitución establece:

1. *"En casos de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general".*
2. *"Los Decretos Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario."*
3. *"Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia."*

La **convalidación de un Real Decreto Ley no supone su conversión en Ley** sino la conversión de un Real Decreto Ley provisional en un Real Decreto Ley definitivo. (Tribunal Constitucional),

Adicionalmente la practica o costumbre parlamentaria **ha impuesto la ratificación o derogación del decreto ley previo debate y votación a la totalidad en torno al mismo**, lo cual se considera como paso previo en todo caso.

El real decreto-ley es una norma jurídica con rango de ley especialmente creada para que el Gobierno pueda responder con rapidez ante situaciones urgentes.

Le compete al propio Gobierno, **discrecional y no arbitrariamente, interpretar y aplicar la "extraordinaria y urgente necesidad"**, esto es un concepto jurídico indeterminado.

La apreciación gubernamental de esta "necesidad" **únicamente podrá ser controlada por el Congreso, a un nivel político, y, en su caso, por el Tribunal Constitucional** cuando dicha apreciación sea claramente abusiva o arbitraria.

Destacamos que sea el Congreso y no las dos cámaras las procedentes para la revisión. Esto hace que algunos autores no la consideren como una verdadera "ley"

4.3 Conclusiones

Adicionalmente a la Ley Ordinaria y la Ley Orgánica, en el ordenamiento jurídico español existen dos tipos de normas con fuerza de ley emanadas del Poder Ejecutivo, como son el Decreto Legislativo y el Decreto- Ley. El primero se puede dictar por la delegación normativa del poder legislativo y el segundo cuando exista el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad.

Ambos tipos de decretos, están posicionados jerárquicamente a la misma altura de que Leyes Ordinarias y Leyes Orgánicas. Y el carácter de posible inconstitucionalidad para ambos, viene establecido por vulneración del principio de competencia.

5 El Reglamento Concepto, Clases y Limites.

5.1 Introducción

La realidad nos demuestra que el Reglamento, **no solo marca la pauta habitual y cotidiana en la actuación de los órganos administrativos**, además tiene una presencia cada vez más significativa en la esfera jurídica de los particulares, especialmente en aquellos sectores en donde existe un interés que trasciende al ámbito de los actores privados y compromete valores y bienes jurídicos colectivos.

El Reglamento es ***“toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la ley”***. (Garrido –Falla)

El Reglamento **tiene en común con la ley, que es una norma escrita**, pero difiriendo en todo lo demás. Siendo secundario, inferior y complementario a la ley, pero sometido absolutamente a ésta.

Ese valor subordinado a la ley tiene dos significados.

- **Aunque sea posterior a ésta, no puede derogarla y, por el contrario, toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre cualquier Reglamento.**
- Que no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria. **La ley puede entrar a regular cualquiera que con anterioridad haya sido regulada por el Reglamento.**

5.2 Características.

Como **características principales** de los reglamentos, se pueden destacar:

- Se trata de disposiciones **normativas de carácter general**.
- Han de **proceder del poder ejecutivo** en cualquiera de sus manifestaciones.
- Los reglamentos se dictan en ejercicio de una competencia que es propia a los órganos de la Administración que lo dicta: **no constituyen, por tanto, la legislación delegada**.
- En general, se **refieren a materias y servicios de la Administración**. Por su contenido **son normas de Derecho objetivo que se integran en el “bloque de la legalidad”** y que se imponen a la Administración en su actuación concreta.
- Pueden adoptar **formas diversas**: Decretos, Órdenes Ministeriales, etc.
- El Reglamento es una norma **subordinada respecto a la ley**. Es una norma necesitada de justificación, caso por caso, condicionada, con posibilidades limitadas y tasadas.
- Es libremente justiciable por el juez o fiscalizable judicialmente.

El principio **de supremacía de ley** opera en la actualidad bajo dos manifestaciones:

- **Reserva material de ley**, que comprende el conjunto de supuestos o materias respecto de los cuales la Constitución exige su regulación por norma con rango de ley.
- **Reserva formal de ley**, que cualquier materia por mínima que sea, cuando es objeto de regulación por ley, ya no puede ser regulada por Reglamento.

En relación a su **naturaleza jurídica**, es un problema controvertido en la doctrina jurídica, en cuanto a **si es o no un verdadero acto administrativo**.

5.3 Diferenciación.

5.3.1 Diferencia con el acto administrativo.

- El Reglamento se **integra en el Ordenamiento Jurídico**, en tanto que el **acto administrativo está producido por éste** y no es sino una aplicación del mismo.
- El **Reglamento tiene vigencia hasta la derogación**, en tanto que el acto administrativo se **agota en el simple cumplimiento**.
- El Reglamento **puede ser objeto de derogación o modificación** sin más limitaciones que la que imponen las normas para la adopción del nuevo Reglamento. El acto administrativo, por el contrario, tiene **límites para su revocación**.
- La **ilegalidad** de un Reglamento es siempre sancionada **con la nulidad de pleno derecho**, en tanto que la del acto administrativo es, como regla general, **sancionada con su anulabilidad**.
- El Reglamento es una **norma general, abstracta** e impersonal ya que no está referida a administrados concretos. Los actos administrativos son específicos como ocurre con los destinatarios de los actos administrativos.
- Frente a la impugnación de un acto administrativo puede oponerse, **excepción del acto firme**, excepción que no cabe frente al acto normativo, contra el cual cabe **una acción intemporal de nulidad**

5.3.2 Diferencia con los Decretos leyes y los Decretos legislativos.

Los Decretos leyes y los Decretos legislativo, se **distinguen de los reglamentos** es que invaden competencias de poder legislativo.

La producción de los reglamentos, es una **competencia propia del poder ejecutivo**. Artículo 97 CE:

“El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

5.4 Clases de reglamentos.

En función del punto de vista que empleemos, se pueden realizar distintas clasificaciones.

5.4.1 Por la relación del reglamento con la ley:

1. **Independientes**. Son los Reglamentos dictados sin una ley previa. Reglamentos que reglan materias de las que no se ha ocupado el legislador. Se trata de una figura tradicional en España, y de la cual el Gobierno hace en la practica un uso frecuente y generalmente admitido por la jurisprudencia principalmente en el ámbito de los llamados Reglamentos administrativos).
2. **Ejecutivos**. Son los reglamentos que se dictan sobre la base de una Ley preexistente y en virtud de la técnica de la revisión normativa.
3. **De necesidad**. Tradicionalmente las normas que dicta la Administración para hacer frente a situaciones extraordinarias o de emergencia

5.4.2 Por razón de los efectos:

Jurídicos. Son reglamentos **con efectos ad extra de la propia Administración** pues tienen por objeto incidir sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en cuanto tales, y se dictan en virtud de la

relación de supremacía general que existe entre la Administración y los ciudadanos. La doctrina entiende que para dictar este tipo de Reglamentos que inciden en el ámbito externo o relacional es precisa una **previa autorización o habilitación legal**, es decir, ha de tratarse de **Reglamentos ejecutivos**.

Administrativos. Son los que regulan la organización administrativa y, asimismo, los que se **dictan dentro del ámbito de una relación especial de poder** (o bien en virtud de relaciones de sujeción especial) **que ligan a determinados sujetos con la Administración**.

5.4.3 Por su origen:

1. **Estatales.** Los que provienen del Gobierno, al que el artículo 97 de la CE atribuye explícitamente el ejercicio de la potestad reglamentaria y se aprueban y publican bajo la forma de Real Decreto.
2. **Autonómicos.** Son los que emanan de las Comunidades Autónomas.
3. **Locales.** La Ley Reguladora de las Bases de régimen Local distingue el Reglamento Orgánico de cada Entidad, por el que cada Ente se organiza, de las Ordenanzas locales, que son normas de eficacia externa de la competencia del Pleno de la Entidad, y los Bandos, que el Alcalde puede dictar en materias de su competencia.
4. **Reglamentos de los Entes Institucionales** (Organismos autónomos estatales, autonómicos y locales) y reglamentos de los **Entes corporativos** (Colegios Profesionales).

5.5 La potestad reglamentaria

Es el **poder en virtud del cual las Administraciones públicas dictan reglamentos**. Es por tanto la potestad (o poder), más grave y necesitada de mayor profundidad al ser ejercida, pues implica la participación en la formación del ordenamiento legal. Por la cual, la **Administración además de ser sujeto de Derecho**, tiene **capacidad** de formar en cierta medida **su propio ordenamiento y el de los demás**.

5.5.1 Titularidad de la potestad reglamentaria.

En nuestro Derecho, el artículo 97 de la Constitución, confiere la **potestad reglamentaria, genérica y expresamente al Gobierno en su conjunto**.

En este sentido hay que destacar el art 128 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas PACAP que sobre la Potestad reglamentaria establece:

“1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”

Adicionalmente pronuncia el artículo 61 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al establecer que a los ministros corresponderá: “...a) *Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento*”.

El artículo. 153 c) de la Constitución, **reconoce implícitamente la potestad reglamentaria a las Comunidades Autónomas**, al establecer que: “*El control de la actividad de los órganos de las*

Comunidades Autónomas se ejercerá: ...c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de su administración autónoma y sus normas reglamentarias”.

Los arts. 140 y 141 de la CE y artículo 4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, **otorga la potestad reglamentaria a los Plenos de los Ayuntamientos y a las Diputaciones provinciales** (en lo que se refiere a ordenanzas y reglamentos) y a los Alcaldes (para dictar Bandos). En cuanto a los **Entes Institucionales y Organismos autónomos, se rigen por las leyes que les son propias.**

TIPO DE ADMINISTRACIÓN	DE	ÓRGANOS COMPETENTES	FORMA DE LAS DISPOSICIONES
Administración del Estado		Consejo de ministros	Real Decreto del Consejo de Ministros
		Presidente del Gobierno	Real Decreto del Presidente del Gobierno
		Comisiones delegadas del Gobierno	Orden del ministro de la presidencia
		Ministros	Orden del ministro competente
Administración Autonómica		Consejo de Gobierno	Decreto del consejo de Gobierno
		Presidente de la comunidad	Decreto del presidente
		Consejeros	Orden del Consejero
Entidades Locales		Pleno de la corporación	Reglamentos y Ordenanzas

5.5.2 Límites a la potestad reglamentaria.

Los límites de la potestad reglamentaria, para la Administración en cualquiera de sus tres niveles, estatal autonómica o local, pueden ser **materiales o formales**.

5.5.2.1 Límites formales:

- **La competencia**

La **atribución competencial para la producción reglamentaria** se realiza el art. 97 CE y el art. 22 Ley 50/1997, del Gobierno (que remite al título V 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP). de manera explícita y concreta, **en favor del Gobierno**; entendiendo el mismo como órgano colectivo y colegiado distinto de los miembros individuales que lo forman. Pero a la vez, al **establecer la garantía institucional de la autonomía en favor de municipio, provincia y CCAA, está admitiendo una potestad normativa propia a entidades**. Potestad que **incluye, como mínimo** (y en el caso de la Administración Local. también como máximo) **la potestad reglamentaria**.

Como hemos visto en los artículos 128.1 de la ley 39/2015, de 1 octubre del PACAP y art 61 del LRJPAC, la potestad es derivada y subordinada, restringida al ámbito del departamento y de las relaciones especiales de supremacía.

- **Procedimiento de elaboración**

Por lo que respecta al procedimiento para la elaboración para los reglamentos, habrá éste de ajustarse al establecido en el art. 26 de la Ley 50/1997 del Gobierno, modificado con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición final 3.12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP, y que en sus líneas

generales es común para los **anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias**.

El incumplimiento de estos límites formales supone que nos encontremos **ante un reglamento ilegal, y la consecuencia que de ello deriva es la nulidad del mismo**.

5.5.2.2 Límites Materiales

Los reglamentos deben respetar unos límites materiales:

- **El respeto a los Principios Generales del Derecho.**

La constitución de 1978 recoge y consagra de manera resuelta el sometimiento **de la potestad reglamentaria a los Principios Generales del Derecho**: en concreto: el art 103.1 "*Sometimiento pleno a la ley y el derecho*", por parte la administración-y el art. 9.3, garantiza la "*interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos*".

- **La materia reglamentaria.**

Una primera acotación de la materia que puede ser objeto es la materia administrativa, pero aún dentro de ella no toda. Existiendo dos bloques diferenciados, **aspectos organizativos y las directrices básicas** en el caso de que la regulación imponga a los ciudadanos obligaciones o **deberes o bien limite derechos y libertades**.

- **Subordinación a la ley.**

La Constitución establece el **principio de reserva de ley**, en virtud del cual solo por ley formal aprobada por el Parlamento, pueden regularse determinadas materias. Este principio de reserva material de ley significa Que el reglamento no puede entrar a regular *ex novo* estas materias, solo podrá hacerlo cuando la ley expresamente le autorice para ello.

La primacía de la Ley implica que los Reglamentos están subordinados a la Constitución, a las leyes y a las disposiciones normativas con fuerza de ley, sin que, obviamente, puedan derogarlas suplirlas o excluirlas.

Además, **no se establece en nuestra Constitución, el principio de reserva reglamentaria**, por lo que la ley podrá regular cualquier materia, sea o no de las reseñadas a ella por la Constitución.

- **Jerarquía normativa**

Los reglamentos están **subordinados a la CE, a las leyes y al resto de normas con rango de ley**. Pero así mismo, éstos se hallan jerarquizados entre sí, siendo su eficacia distinta según el rango de la autoridad que los dicte. Así, dispone el art. 128.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP que:

"las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior"

Igualmente son también **ilegales** los reglamentos que **no respeten el principio de irretroactividad desfavorable**.

Mencionar el **concepto de Inderogabilidad Singular de los reglamentos**.

Según el art 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP:

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Supone por tanto que la autoridad que ha dictado un reglamento, (o un superior jerárquico), que podrían derogarlo, no pueden mediante acto singular excepcionar en un caso concreto la aplicación de un reglamento.

5.5.3 Consideraciones adicionales

Cabe mencionar **adicionalmente el control judicial** por superación de alguno de los límites (formales o materiales)

Si un reglamento **que incumple los límites formales o materiales** que hemos indicado (con la extralimitación de uno solo bastaría), se puede proceder a impugnar el mismo mediante un **recurso judicial contencioso-administrativo**, El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, comprobada la existencia del vicio formal o material anulará total o parcialmente la norma impugnada.

Adicionalmente **los Juzgados y Tribunales** (Ley Orgánica del Poder Judicial) permite **la no aplicación de un reglamento ilegal** (por vulnerar la CE, las leyes o reglamentos superiores) **ya que la ilegalidad del mismo implica su no pertenencia al ordenamiento jurídico al ser nulo de pleno derecho**

5.6 Procedimiento de aprobación de los reglamentos

La reforma operada por la ley 39/2015, de 1 de octubre del PACAP, junto con algunas mejoras en la regulación vigente sobre jerarquía en art. 128 (**Potestad Reglamentaria**), art 129. (**los principios de buena regulación**) y art 131 (**publicidad de la norma**), se incluyen varias novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de norma.

Destaca la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, **la opinión de ciudadanos y empresas acerca** de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, **la necesidad y oportunidad** de su aprobación, **los objetivos** de la norma y **las posibles soluciones** alternativas regulatorias y no regulatorias art. 132 (**Planificación normativa**) y art 133. (**Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos**).

El art. 132 de la Ley 39/2015, establece que las Administraciones **divulgarán un Plan Anual Normativo** en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente.

5.7 Límites de los reglamentos.

Las limitaciones son la siguientes:

- En Materia reglamentaria; No podrá regular **aquellas materias que son competencia exclusiva del Poder Legislativo**. Solo pueden dictarse reglamentos en materias propias de la Administración.
- **Principio de legalidad:** El Reglamento debe ajustarse a la legalidad, respetar el principio de reserva de Ley y la jerarquía de normas, de modo que el Reglamento no puede

contradecir lo dispuesto en la Ley, y, además, el dictado por una autoridad inferior no puede contradecir el dictado por otra de superior rango.

- **Competencia.** Es nulo de pleno derecho, si es aprobado por el organismo no competente.
- **Aprobación.** Debe ajustarse al procedimiento legalmente establecido,

5.8 Control de los reglamentos.

5.8.1 La nulidad de pleno derecho

Siendo la **anulabilidad la sanción común en los actos administrativos**; la sanción general es la nulidad de pleno derecho en el caso de los reglamentos ilegales.

Art 47.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre del PACAP.

*“También **serán nulas de pleno derecho** las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”*

5.8.2 La inaplicación de los reglamentos.

Los jueces tienen una función de enjuiciamiento previo sobre la conformidad de los reglamentos con las leyes, el cual es previo a la aplicación de los mismos.

Artículo 6 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

“Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.

5.8.3 Declaración de oficio de la nulidad de los reglamentos por la propia administración.

La propia administración autora de la norma, puede declarar de oficio la nulidad del reglamento ilegal, con los efectos e indemnizaciones que procedan. Art 106 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP.

Por otro lado, en el art 112.3 se establece, *“Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”*, es decir hay que recurrir a la vía contencioso-administrativa

5.9 Conclusiones.

El reglamento es una norma que, para llegar a ocupar **la importante posición** que actualmente tiene en todos los ordenamientos del mundo, ha debido **superar su aparente contradicción con el principio de separación de poderes**, que es una base esencial de todos los sistemas constitucionales europeos, y que parece **imponer la atribución exclusiva al Parlamento del poder de dictar normas**.

Su importancia como norma, es tanto por lo **que significa que el poder ejecutivo tenga la facultad de disponer y, por tanto, crear Derecho**, como por la **importancia cuantitativa** que tiene el

reglamento dentro del universo de las normas, que está ocupado en un elevadísimo porcentaje por disposiciones de dicha categoría.

6 Otras fuentes de Derecho administrativo

6.1 Introducción.

La costumbre es una de **las fuentes de producción** de la norma administrativa. No obstante, la costumbre pierde prácticamente importancia, dado el carácter predominante de derecho escrito en el Derecho administrativo. Tienen interés determinadas manifestaciones relacionadas con el derecho consuetudinario: las prácticas administrativas y los precedentes administrativos, como expresión de la vigencia de determinados criterios que se aplican en la actividad administrativa.

6.2 La Costumbre

La Costumbre puede definirse como **la expresión del sentir popular o modelo de conducta popular expresado por la repetición de una serie de actos sobre un orden determinado de derecho**. Se trata, por tanto, **una norma creada e impuesta por el uso social**.

El artículo 1.1 del Código Civil establece que las fuentes del Derecho español son la **Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho**.

De acuerdo con el artículo 1.3 del Código Civil, para que la costumbre tenga el carácter de fuente del Derecho es necesario **que no sea contraria a la moral o al orden público y, que sea probada**; es decir, quien invoca la existencia de una costumbre jurídica **está obligado a demostrar su existencia**, con los requisitos propios de las mismas.

Se habla, por tanto, de la existencia de un **elemento material** (la reiteración en el comportamiento) **y un elemento espiritual** (la elevación de ese comportamiento a modelo de conducta, de observancia preceptiva), distinguiéndose la costumbre jurídica de los usos sociales.

6.2.1 Tipos de costumbre:

Costumbre *secundum legem*, que regula una materia que ha sido objeto de una Ley, pero ampliándola o dándole una interpretación peculiar.

Costumbre *praeter legem*, que regula una materia que no ha sido regulada por la Ley.

Costumbre *contra legem*, regula una materia de forma distinta a como aparece regulada en la Ley, es por ello inaplicable en la mayor parte del Estado.

Sin embargo, debido al **principio de legalidad**, el Derecho Administrativo es un **derecho fundamentalmente positivista**, integrado en su casi totalidad por normas escritas Leyes y Reglamentos- y, por esta razón, la costumbre presenta en Derecho Administrativo **un valor francamente limitado**. La existencia de la costumbre como fuente del Derecho Administrativo, así como su jerarquización, a diferencia de lo que sucede con la costumbre como fuente del Derecho civil, ha sido discutida por la doctrina, si bien debe de afirmarse que aun por parte de quienes la consideran **como fuente del mismo reconocen su escasa virtualidad**. Dentro de la costumbre, podemos distinguir los siguientes supuestos:

- **Costumbre a la que se remite la ley, (*Secundum Legem*)**, si debe reconocérsela como **fuentes del Derecho administrativo**.
- La Costumbre **como expresión de las prácticas administrativas (*praeter legem*)**. En este caso, la **Costumbre no se considera fuente del Derecho administrativo ya que la Administración no se encuentra vinculada por el precedente administrativo**, debiendo únicamente motivar su actuación cuando se separe del criterio seguido anteriormente.

6.2.2 Los Principios Generales del Derecho.

Los principios generales del derecho, dice el artículo 1 del Código Civil, **"se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico"**. En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró en su sentencia de 2 de febrero de 1981 que *"Los principios generales del Derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico"* como afirma el artículo 1.4 del Título Preliminar del Código Civil, que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos.

Estos principios generales del derecho expresan, en el concepto de García de Enterría, **"los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal, las convicciones ético jurídicas fundamentales de una comunidad"**. En su opinión, no se trata simplemente de unas vagas ideas o tendencias morales que puedan explicar el sentido de determinadas reglas, sino de principios del derecho, esto es, formulas técnicas del mundo jurídico, que, por ser generales, trascienden de un precepto concreto y organizan y dan sentido a muchos. Este autor viene a destacar su funcionalidad como **límite al ejercicio de la actividad discrecional de la Administración, al ser informadores de todo el ordenamiento jurídico**.

La propia Constitución española regula desde los derechos fundamentales y libertades públicas, hasta los **principios generales más típicamente administrativos**, como son: el **principio de irretroactividad** (artículo 9), **de igualdad, mérito y capacidad** para el acceso a las funciones y empleos públicos (artículos 23.3 y 103.2), de **responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas**, o de regularidad y continuidad del funcionamiento de los servicios públicos (mantenimiento de los servicios esenciales como un límite al ejercicio del derecho de huelga); el **principio de buena fe** (limitando el poder para ejercerlo de forma razonable); **igualdad en la aplicación de la ley** (artículo 14) el **principio de la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder** (artículo 9.3, que prohíbe toda situación de indefensión e impone la objetividad como regla de la actuación administrativa).

6.2.3 La Jurisprudencia

En último lugar, debemos destacar por su enorme importancia, **el cometido de la jurisprudencia, que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 del Código Civil)**.

La jurisprudencia por sí solo no integra el ordenamiento jurídico, pero la doctrina del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar dicho ordenamiento **establece unas pautas que, si no vinculan directamente al resto de los órganos judiciales**, sí condiciona en gran manera su ejercicio por la tutela del órgano del que emana.

Además, hay dos fuentes de doctrina jurisprudencial que proceden de nuestra integración europea:

- **Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos**, que vincula debido al convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas de 1950 (ratificado por España en 1979).
- **Decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea**.

Las normas emanadas de la UE obligan con su sola publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El principio de primacía establece la prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario sobre el nacional.

6.2.4 Conclusiones

El **precedente y la costumbre son dos instituciones radicalmente distintas**, y aunque nada tienen que ver entre sí, ambas tienen en común el hecho de que procedan de la reiteración de comportamientos con un mismo contenido. Pero, aun así, el precedente nada tiene que ver con la costumbre.

Los principios generales del derecho, dice el artículo 1 del Código Civil, ***"se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico Normativo"***. Por último incidir en la importancia de la jurisprudencia **que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 del Código Civil)**.

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los Principios Generales del Derecho

- Fuentes directas:
 - **Fuentes escritas:** la Constitución, la ley, los Tratados internacionales, los reglamentos estatales y los reglamentos dictados por otras entidades públicas. El Derecho Administrativo español está dominado por el principio de la ley escrita.
 - **Fuentes no escritas:** la costumbre y los Principios Generales del Derecho.

- Fuentes indirectas:
 - **Jurisprudencia:** Art. 1.6 CC *La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo...*
Adicionalmente la llamada jurisprudencia menor, como las resoluciones de la Audiencia Nacional, o el Tribunal Económico Administrativo Central.
 - **Doctrina Científica:** consiste en **reconocer al precedente** fuerza vinculante siempre que se de identidad subjetiva y objetiva sustancial entre ambos supuestos comparados

Fuentes del Derecho

Materiales (Capacidad) Normativa

- Poder Legislativo
- Poder Ejecutivo
- El pueblo

Formales (Forma)

- Directas
 - Primarias (Escritas):
 - Constitución
 - La Ley
 - El reglamento
 - Secundarias (NO Escritas)
 - Costumbre
 - Principios Generales del Derecho
- Indirectas
 - Tratados internacionales
 - Jurisprudencia
 - Doctrina Científica

Sobre la ley estudiar:

- Definición.
- Características de la ley
- Requisito internos y externos de la ley
- Aprenderse las clases de leyes.
- Leyes orgánicas. Definición, relación con otras leyes. Los estatutos de autonomía.
- Leyes ordinarias. Materias excluidas, Aprobación

Orden Jerárquico

- Fuentes primarias
 - Legislativas (Leyes)
 - Constitución
 - Leyes y disposiciones del Gobierno con fuerza de ley
 - Administrativas (Reglamentos)
 - Reglamentos del presidente del Gobierno y del consejo de ministros
 - Reglamentos de las comisiones delegadas del Gobierno
 - Reglamentos de los ministros
- Fuentes secundarias
 - Costumbre
 - Principios Generales de derecho

Tipos de leyes:

- Estatales
 - Orgánicas
 - Materia del art. 81.1 CE
 - Estatutos de autonomía.
 - De transferencia o delegación
 - Ordinarias:
 - De pleno y de comisión
 - Marco
 - Armonización
 - Básicas
 - Otras
 - Mixtas
 - Medidas
- Autonómicas

Dos tipos de disposiciones: **Reales Decretos Legislativos y Real Decreto Ley**

- Ver aspectos comunes: **ambas emanan del Gobierno y tienen el mismo valor que las leyes ordinarias**

- Ver las diferencias entre los dos: **en los decretos legislativos la intervención de las cortes a priori** legitimando, en los **decretos ley, es a posteriori**. El fundamento de los **primeros es por delegación**, y en los segundos por extraordinaria y urgente necesidad.
- En los Decretos legislativos revisar: regulación, concepto, requisitos, clases (Textos articulados y textos refundidos), el contenido y los límites de la delegación, así como el control.
- En los Decretos-Ley, revisar: regulación, concepto, el presupuesto habilitante y límites. La convalidación, derogación, y conversión en ley, control,

En el reglamento estudiar:

- Definición.
- Que significa **subordinación a la ley**
- Características principales:
- Principio de supremacía de ley
- Similitud y Diferenciación con el acto administrativo
- Similitud y Diferenciación con los decretos leyes y decretos legislativos.

Clases de reglamentos.

- Según relación con la ley (Independientes, ejecutivos, de necesidad)
- Según los efectos (Jurídicos y administrativos)
- Según el origen (estatales, autonómicos, locales, entes institucionales)

Potestad reglamentaria, estudiar:

- Definición.
- Quien tiene la titularidad.
- Límites.
- Formales (competencia y procedimiento de elaboración)
- Materiales (respeto a los PGD, la materia reglamentaria, subordinación a la ley y jerarquía normativa)

Elaboración y Límites de los reglamentos.

Sobre el control de los reglamentos: nulidad de pleno derecho, e inaplicación de los reglamentos por los jueces, nulidad por la propia administración:

Costumbre:

- Definición,
- importancia y elementos
- Tipos

Principios Generales del Derecho

- Art 1 CC
- Sentencia del TC: El carácter informador de todo el ordenamiento jurídico.
- Ejemplos de PGD en el ámbito administrativo

Jurisprudencia

- Art .1.6 CC.
- El papel del TS al interpretar y aplicar.
- Otras fuentes de doctrina.

8 GLOSARIO

- Art.; Artículo
- CE Constitución Española
- CC: Código Civil
- PACAP: Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- LRJPAC: Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común

9 TEST

- 1) Dentro de las fuentes del derecho, podemos decir el tribunal constitucional:
 - a) Actúa como legislador negativo
 - b) Establece la jurisprudencia, interpretando las leyes.
 - c) Tiene el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
 - d) a) y c) Son validas
- 2) En cuanto a la Jerarquía Normativa, podemos decir que:
 - a) Existen dos criterios fundamentales: Primacía del Derecho escrito y la jerarquía del órgano del que emana la norma,
 - b) Prima la Constitución y se subordinan las disposiciones administrativas a la jurisprudencia y la costumbre.
 - c) Puede existir retroactividad en disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales.
 - d) En función del principio de jerarquía normativa, no hay relación entre el órgano del cual emana la norma y el rango y fuerza
- 3) Una ley estatal que contiene los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en una materia, es:
 - a) Una ley orgánica
 - b) Una ley de armonización
 - c) Una ley de bases
 - d) Una ley marco
- 4) Las disposiciones que contradigan lo establecido en una norma de carácter superior:
 - a) Son nulas de pleno derecho
 - b) Deben ser recurridas ante el Tribunal Supremo
 - c) Son anuladas por las Cortes Generales
 - d) Son anuladas por el tribunal constitucional.
- 5) ¿Qué artículo del Código civil establece las fuentes del derecho?
 - a) Ninguno, se especifica en la constitución.
 - b) Ninguno, se especifica en la ley 39/2015 de PACAP.
 - c) Art 1.
 - d) Art 2.
- 6) No es fuente directa del derecho administrativo:
 - a) Los tratados internacionales desde su firma
 - b) La costumbre
 - c) El reglamento
 - d) Los principios generales del derecho
- 7) Los reales decretos son:
 - a) Una manifestación de la potestad reglamentaria del Gobierno
 - b) Una norma legal del Gobierno que requiere autorización de las cortes generales

- c) Una norma legal del Gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad
 - d) Una disposición administrativa de carácter general de un Ministerio
- 8) Señalar cual es la opción correcta:
- a) La costumbre tiene amplia aplicación en el derecho administrativo
 - b) La administración está vinculada por el precedente administrativo.
 - c) Todos los tipos de costumbre, son admitidos como fuentes del derecho administrativo
 - d) Costumbre a la que se remite la ley, (Secundum Legem), si debe reconocérsela como fuente del Derecho administrativo
- 9) Señalar cuál de estas premisas es verdadera:
- a) Las administraciones divulgaran un plan semestral normativo con todas las propuestas normativas
 - b) El art 130 ley 39/2015 favorece la evaluación “a priori”, al objeto de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación,
 - c) La redacción de los reglamentos estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.
 - d) Solo es preceptivo el dictamen del consejo de estado en el caso de anteproyecto de ley o real decreto legislativo.
- 10) Respecto a la potestad reglamentaria, las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan:
- a) los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior
 - b) las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior
 - c) los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior
 - d) las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior

9.1 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	A
2	A
3	B
4	A
5	C
6	A
7	C
8	D
9	C
10	B

10 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. *Tratado de derecho administrativo y derecho público general*. Santiago Muñoz Machado.
2. *Tratado de Derecho Administrativo*. Garrido Falla.
3. *Manual Básico de Derecho Administrativo*. Eduardo Gamero
4. *Guías Jurídicas*. Wolters Kluwers